

1502535-10.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... e acondicionadas para a venda no varejo, configurando o tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502535-10.2021.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1502535-10.2021.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

VINICIUS AMÂNCIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de outubro de 2021, por volta das 10h14min, na Avenida São João, altura do nº 404, Ponte São João, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente R.R. O. R. da C, então com 15 anos de idade, trazia consigo, para fim de tráfico, as substâncias entorpecentes descritas na denúncia,

que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a peça inicial que, na data dos fatos, o acusado e o adolescente se ajustaram a fim de comercializar drogas no local acima mencionado. Para tanto, receberam sacolas plásticas contendo diversas porções de entorpecentes variadas e permaneceram no local entre 08h00min e 20h00min, mediante promessa de remuneração de R\$ 150,00, por dia de trabalho.

O réu e o menor, então, dividiram entre si as sacolas e se dirigiram ao local conhecido como ponto de tráfico, onde realizaram diversas vendas.

Enquanto comercializavam o tóxico, foram surpreendidos por guardas municipais, que patrulhavam as imediações. Ao notarem a presença da viatura, o acusado e o adolescente tentaram fugir em desabalada carreira, levando consigo as sacolas plásticas.

Ambos acabaram detidos e, em revista pessoal, os agentes municipais apreenderam, em poder do réu, uma sacola plástica contendo 53 porções de cocaína, 36 porções de "crack" e 10 frascos de lança-perfume, além da quantia de R\$ 40,00 em cédulas de pequeno valor. Na posse do adolescente, foram localizadas 56 porções de maconha e a importância de R\$ 67,00.

Tanto o réu como o adolescente admitiram a traficância.

Assim, pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi o acusado preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada e recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a Promotora de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade. Requereu, ainda, a imposição de regime inicial fechado.

A defesa, em preliminar, arguiu a nulidade da prova, em razão de sua ilicitude, uma vez que a prisão do imputado foi realizada por guardas municipais, os quais não têm legitimidade para efetuar diligências afetas somente à Polícia Judiciária, conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal. Alegou, ainda, violação ao disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Sustentou a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, o que torna dúbia a prova da materialidade. Salientou, ainda, que a negativa de autoria ofertada pelo réu deve ser considerada como elemento de prova. Alegou, outrossim, que os depoimentos dos guardas municipais devem ser recebidos com reserva, ante o interesse que tem em justificar sua conduta. Alternativamente, pediu a desclassificação do delito para uso próprio; afastamento da causa de aumento de pena do envolvimento do adolescente; imposição de regime inicial aberto; aplicação do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, substituição da corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

Afasto as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

Não há falar em ilegalidade na atuação dos guardas municipais quando da prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, "in casu", não houve qualquer investigação policial exercida pelos guardas municipais, mas sim situação de flagrância, o que autoriza a prisão, vez que o tráfico de substância entorpecente é crime de natureza permanente. Assim, permanecendo o agente em situação de flagrância, não há qualquer ilicitude no fato dos guardas municipais terem dado voz de prisão ao acusado e apreendido a droga. Ademais, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante.

E ainda que se desconsiderasse o enquadramento dos guardas municipais como "autoridades policiais" - a quem cabe o dever de efetuar prisões em flagrante - permaneceria a eles a possibilidade de realizá-las, uma vez que o dispositivo legal

acima referido permite, de forma expressa, tal faculdade a “qualquer do povo”. Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “Tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Nulidade do auto de prisão. Flagrante realizado por guardas municipais. Possibilidade. Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal. Mácula inexistente. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes”. (HC nº 296.728/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/09/2014).

Note-se, outrossim, que a prisão foi devidamente comunicada à autoridade judiciária competente, que lavrou o auto de prisão respectivo e firmou a nota de culpa ao réu, ratificando e convalidando, portanto, os atos praticados pelos agentes municipais. Importa observar, por oportuno, que não obstante o disposto no artigo 144, § 8º, da Carta Magna, prever, como função da guarda municipal – relativamente ao município – a “proteção de seus bens, serviços e instalações”, inexistente falar em proibição de que prendam em flagrante pessoas suspeitas de praticarem crimes, bem como que apreendam bens relacionados aos delitos.

Entendimento contrário, como quer a defesa, implicaria equivocada proibição às guardas municipais, sem qualquer base normativa ou justificativa razoável.

Também não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos guardas municipais.

Quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que ensejou a presente ação penal.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que “em processo penal, vigoram os princípios de que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)’” (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Afastadas as preliminares, no mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 46/48, 90/92 e 112/116), os quais confirmam que as

substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Não prospera a alegação da defesa de ausência de materialidade. Realmente, quanto à higidez da prova sob a ótica da cadeia de custódia, acima do cumprimento estrito das formalidades em si, deve-se observar a finalidade do instituto.

Assim, eventual irregularidade no citado procedimento da cadeia de custódia, além de não implicar na nulidade da prova produzida, encerra matéria afeta ao seu valor probatório, cuja análise deve ocorrer no momento oportuno, quando do julgamento da causa.

Ensinam Gustavo Badaró, Guilherme de Souza Nucci e Rogério Sanches Cunha: "(...) mesmo com tais riscos, defende-se que as irregularidades da cadeia de custódia não são aptas a causar a ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com redobrado cuidado e muito maior esforço justificativo, no momento da valoração. Não é a cadeia de custódia a prova em si, mas sim uma 'prova sobre prova' (...) "(cf. Processo Penal, 8ª ed., São Paulo, RT, 2020, pág. 4514).

Incontrovertida a prova de autoria.

Na fase administrativa, o acusado negou o delito, dizendo que estava no local na companhia do adolescente, para comprar "k2" de um popular. Com a chegada da Guarda Municipal todos correram, ocasião que o popular jogou a sacola. Acabou detido. Em Juízo, permaneceu em silêncio dizendo que falou na delegacia o que tinha para falar.

A negativa na fase administrativa restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

As testemunhas Allisson Marconni Rufino de Sousa e Fábio Augusto de Souza, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas e do dinheiro em poder do réu e do adolescente. Esclareceram, ainda, que não conheciam o réu e ambos assumiram que estavam traficando.

As palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação.

São depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Para enfraquecer tais depoimentos, imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E como não conheciam o acusado, não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminá-lo falsamente, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

As substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas para a venda no varejo, configurando o tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado. É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Não é caso de desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas como pretende a defesa, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da apreensão.

Demonstrada, outrossim, a causa especial de aumento de pena descrita na denúncia, uma vez que restou cabalmente demonstrado nos autos que o comércio clandestino

praticado pelo acusado envolveu adolescente.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação. Ante o exposto, afastadas as preliminares, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu VINICIUS AMÂNCIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista se tratar de réu primário.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Em seguida, aumento a pena de 1/6 (um sexto), ante a incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, somando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Reduzo sua pena de 2/3 (dois terços), somando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) diárias, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Primário, poderá cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto, de acordo com a jurisprudência mais recente dos nossos tribunais, observando que poderá apelar em liberdade, vez que respondeu solto ao processo.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, devendo no mesmo prazo frequentar programas específicos relacionados ao uso de drogas existentes na Comarca.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Assim, fica o réu VINICIUS AMÂNCIO, condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) diárias, como incurso no artigo 33, § 4º, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 28 de março de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson

Juiza de Direito